

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5099848-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ELVIRA NUNES FERREIRA

RECORRIDO: LEDIR NUNES FERREIRA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. TEMA 6/STF. SÚMULA VINCULANTE 61. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO REFORMADORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, ante a ausência de vício na decisão embargada e a flagrante pretensão reformadora da embargante. Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5099848-60.2024.4.02.5101

510015613252 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5099848-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ELVIRA NUNES FERREIRA

RECORRIDO: LEDIR NUNES FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União [evento 22, EMBDECL1] em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de medida de urgência [evento 13, RELVOTO1 e evento 13, ACOR2], em que pretendia a reforma de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Substituto da 15ª VF do Rio de Janeiro [evento 42, DESPADEC1, autos de origem], nos seguintes termos:

*"Diante de todo o exposto, **CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA**, na forma do art. 300 do CPC e conforme fundamentação acima, para determinar que os réus, conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS (Tema 793 do STF e Lei nº 8.080/90), procedam, em máximos 30 (trinta) dias a partir da intimação da presente, à liberação e ao fornecimento à parte autora do **MEDICAMENTO RITUXIMABE 500 MG COM DOIS CICLOS (02 AMPOLAS NO PRIMEIRO DIA E 02 AMPOLAS 14 DIAS APÓS, EM CADA CICLO)**, até que sobrevenha nova decisão nos autos. O medicamento em questão deverá ser entregue na residência da parte autora, conforme endereço fornecido na inicial, a saber: **RUA MARECHAL, Nº 26 - TRAVESSA 26 - CASA 3 - REALENGO - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.721-600 - TELEFONES: (21) 993270277 e (21) 991646952** ou, alternativamente, em outro local a ser indicado pelos réus, dentro do prazo para cumprimento, a fim de que a parte autora ou seu representante legal possam nele comparecer, para procederem à retirada do insumo requisitado."*

Aduz que o Acórdão incorre em vício de omissão, na medida em que não teria se pronunciado sobre a impossibilidade de concessão de medicamento não incorporado ao SUS, consoante Súmula Vinculante 61 e Tema n. 6, em repercussão geral. Ao fim, pretende o prequestionamento da matéria constitucional, o saneamento do vício indicado e reformar o Acórdão.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 18 e 22] e isento de custas.

O recurso em tela é de motivação vinculada, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na espécie, o embargante indica a ocorrência de vício de omissão, na medida em que não teria se pronunciado sobre a impossibilidade de concessão de medicamento não incorporado ao SUS, consoante Súmula Vinculante 61 e Tema n. 6, em repercussão geral.

A tese recursal não merece prosperar.

Consoante se extrai do Acórdão recorrido, *"o medicamento **Rituximabe (500 mg)** possui registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS, através da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), apenas aos pacientes que se enquadrem nos critérios de inclusão dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), elaborados pelo Ministério da Saúde, não sendo este o caso do pênfigo vulgar"*.

A hipótese dos autos trata de uso *off label* de medicamento, o que se equipara à concessão de medicamento não incorporado ao SUS, na medida em que, apesar de incorporado, não possui recomendação no PCDT para uso no quadro clínico da parte autora.

Neste sentido, aplicáveis à hipótese os enunciados do Tema 6, em repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 61, que, em regra, vedam o fornecimento, salvo na excepcionalidade de cumprimento dos seguintes requisitos:

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Pois bem. O Acórdão embargado expressamente se manifesta sobre todos os requisitos dispostos no enunciado do Tema 6 do STF, em repercussão geral.

A respeito da negativa de fornecimento na via administrativa e da não incorporação do medicamento pela CONITEC, o Acórdão transcreve trecho do parecer do NAT-Jus, segundo o qual *"O medicamento Rituximabe até o momento não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)3 para o tratamento do pênfigo vulgar*.

A ausência de avaliação pela CONITEC afasta a exigência de negativa administrativa, porquanto o SUS não está autorizado a fornecer medicamento sem a avaliação e aprovação da CONITEC.

Já os demais itens - "c", "d", "e" e "f" - foram enfrentados através do Tema n. 106 do STJ, em recursos repetitivos, os quais discorrem sobre a imprescindibilidade do medicamento, os resultados cientificamente apurados, o esgotamento das alternativas terapêuticas e a incapacidade financeira. Transcrevo:

*"Neste sentido, consta dos autos que a autora já fez uso de alternativas terapêuticas, sem sucesso, razão pela qual foi indicado o uso da **Rituximabe (500 mg)**, que, por sua vez, foi administrado pela paciente em dois ciclos, com bons resultados [evento 29, ANEXO1, autos de origem].*

Verificada a excepcional possibilidade de uso alternativo ou off label, resta analisar se a parte autora demonstrou o cumprimento dos requisitos elencados no Tema 106 (REsp nº 1.657.156), em recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

- i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
- ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
- iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

A respeito do (i) **laudo médico fundamentado**, reitero que a demandante instrui a inicial dos autos de origem com formulário indicativo do uso off label da medicação pretendida, com destaque para o fato de que foram administradas alternativas sem bons resultado, ao passo que a administração da Rituximabe (500 mg) em dois ciclos foi bem sucedida.

Quanto à (ii) **incapacidade financeira de custear o tratamento**, destaco os comprovantes de renda que instruem a inicial, com indicativo de renda mensal de cerca de R\$ 2.379,49 [evento 1, ANEXO2, fls. 8], inviabilizando o acesso à medicação com valor estimado em R\$ a R\$ 9.039,08 e necessidade permanente de uso.

Já no que tange ao (iii) **registro do medicamento na ANVISA**, não paira qualquer dúvida, dada a expressa declaração do NATJUS neste sentido."

Isto posto, flagrantemente não se trata de omissão ensejadora de embargos, mas de pretensão meramente reformadora.

Relativamente ao prequestionamento, oportuno ressaltar, v.g., entendimento jurisprudencial segundo o qual:

"(...) o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema." (REsp 717265, 4ª Turma DJU 12/3/2007, P. 239). De igual modo: "(...) não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir." (STF, EDcl/RE 97558/GO, 1ª Turma, relator Ministro Oscar Corrêa, RTJ 109/1098)."

De igual modo:

"(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada". STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)."

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, ante a ausência de vício na decisão embargada e a flagrante pretensão reformadora da embargante.** Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. **Intimem-se.**